

1008705-44.2019.8.26.0053

Classe: Ação Civil de Improbidade Administrativa

Assunto: Dano ao Erário

Magistrado: RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 11ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... nocivo das funções e empregos públicos, pelo "tráfico de influência" nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos".

Mais a frente pontua:

De forma geral, a improbidade administrativa não reclama tanta elaboração para que seja reconhecida. Estará ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

11ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1008705-44.2019.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1008705-44.2019.8.26.0053

Classe - Assunto

Ação Civil de Improbidade Administrativa - Dano ao Erário

Requerente:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requerido:

Bruno Covas Lopes e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA promovida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de Bruno Covas Lopes, Marcos Rodrigues Penido, Vítor Levy Castex Aly, Raphael do Amaral Campos Júnior e JZ Engenharia e Comércio Ltda.

Narra a inicial, em síntese, ter apurado em inquérito civil (nº 14.0695.000997/2018) omissão da gestão municipal na manutenção e fiscalização do estado dos viadutos no Município de São Paulo, que ocasionou o acidente da ponte localizada na Marginal Pinheiros em 15/11/2018. Informa que no exercício de 2018, os gastos efetuados com a manutenção de tais obras públicas foram ínfimos em relação ao valor previsto em orçamento para tal fim, ressaltando que no ano em curso a previsão orçamentária é menor do que a dos anos anteriores, a evidenciar o descaso da Administração Pública. Afirma que, conforme investigação perpetrada, não eram realizadas vistorias periódicas, violando a legislação e as normas técnicas previstas pela ABNT. Aponta que a obra era propriedade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), e posteriormente foi transferida ao Município de São Paulo, sendo

que no curso do processo administrativo nº 2012-0.0112.898-2, foram identificados problemas estruturais, com iminente risco de ruína.

Em razão do acidente, a Municipalidade de São Paulo contratou a empresa requerida JZ Engenharia e Comércio Ltda. com dispensa de licitação em razão da urgência (artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93), a fim de realizar obras de recuperação do viaduto. No entanto, após a investigação levada a efeito, aponta que a urgência na recuperação do viaduto decorreu de omissão administrativa. Alega o autor que: i) no procedimento de dispensa de licitação realizado pela Municipalidade não foram apresentados pesquisa de preço, projeto básico, projeto executivo, cronogramas físicos e financeiros ou diagnóstico técnico das ações necessárias à recuperação do viaduto; ii) falta de motivação adequada para a contratação da empresa JZ Engenharia; iii) a contratada teria realizado inúmeras subcontratações para execução dos serviços, por não possuir capacidade técnica e equipamentos para a obra, o que se apurou em declarações prestadas pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras em coletiva de imprensa; iv) não haveria contrato assinado com a empresa "JZ" até 31.01.2019, e não foram dimensionados os custos; v) não há qualquer estudo, análise ou levantamento técnico que indique que a melhor solução seria a recuperação do viaduto; vi) a falta de demonstração de compatibilidade dos preços pagos à contratada com aqueles praticados no mercado, dada a ausência de pesquisa de preços; vii) falta de publicação do ato de contratação, tal como preconiza o artigo 26, caput, da Lei 8.666/93.

Sustenta, ainda, que os fatos narrados caracterizam omissão dolosa da gestão municipal, que tinha conhecimento dos problemas estruturais do viaduto e não adotou quaisquer medidas para sua recuperação, o que colocou em risco a vida de milhares de pessoas que por lá trafegam. Em tal contexto, não haveria fundamento para a dispensa de licitação, a gerar a nulidade da dispensa e do contrato.

Aduz que a conduta dos requeridos caracteriza ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário em razão da dispensa indevida de processo licitatório, a teor do artigo 10, inciso VIII, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), assim como ofende os princípios constitucionais da legalidade, moralidade administrativa, impessoalidade, supremacia do interesse público sobre o particular, indisponibilidade do interesse público, competitividade, conforme artigo 11, caput, do mesmo diploma legal.

Postula a responsabilização solidária dos demandados na recomposição do patrimônio público.

Defende, ademais, a responsabilização dos terceiros que concorreram e/ou se beneficiaram dos atos de improbidade praticados por agente público, na forma do artigo 3º, da legislação supra.

Acrescenta, ao final, a ocorrência de danos morais à coletividade, em razão do risco social criado e da ineficiente atuação da Administração Municipal quanto à manutenção e fiscalização dos viadutos do Município, que afetou a vida de número indeterminável de pessoas com a interdição do viaduto, além da interrupção dos serviços e a operação em velocidade reduzida da Linha 9 pela CPTM, adoção da operação PAESE, gerando mais gastos aos cofres públicos.

Por tais razões, pretende a concessão da tutela de urgência para:

- a) determinar a exibição pela Municipalidade de São Paulo do contrato administrativo assinado com a empresa JZ Engenharia e Comércio Ltda. no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00;
- b) suspender a execução do contrato derivado da dispensa de licitação (Processo nº 2018-0.115.692-8) que contratou a obra de recuperação estrutural do "Viaduto sobre a CPTM" Marginal Pinheiros/Leste Via Expressa, pois além da irregularidade de contratação, entende o Ministério Público que não há prova que a recuperação da

estrutura é a medida mais adequada em termos técnicos e mais segura para a população;

c) determinar a indisponibilidade dos bens existentes em nome dos requeridos, através da Central de Indisponibilidade de Bens, bem como bloqueio de veículos, contas correntes, aplicações financeiras e bens imóveis em seus nomes.

Ao final, objetiva a confirmação dos pedidos de tutela de urgência para:

a) condenar Bruno Covas, Vitor Levy Castex Aly, Marcos Rodrigues Penido e Raphael do Amaral Campos Júnior como incurso nos artigos 10, inciso VIII e 11, caput, todos da Lei Federal nº 8.429/92, aplicando-se as sanções dispostas no artigo 12, inciso II, da mesma lei. Subsidiariamente, à aplicação das sanções previstas no inciso III, do mesmo artigo 12 citado: i) perda da função pública; ii) ressarcimento integral do dano; iii) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; iv) pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano; v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

b) condenar JZ Engenharia e Comércio Ltda, como incurso nos artigos 10, inciso VIII e 11, caput, c/c artigo 3º, todos da Lei de Improbidade Administrativa, aplicando-se as sanções dispostas no artigo 12, inciso II ou III, da referida lei, especificamente: i) ressarcimento ao erário; ii) pagamento de multa civil de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial; iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

c) todos os requeridos ao pagamento de dano moral coletivo correspondente a 30% do valor do dano ao erário, totalizando a quantia de R\$ 2.510.198,29.

Foi parcialmente deferida a liminar apenas para determinar a juntada de cópia integral do processo administrativo de dispensa de licitação, bem como do instrumento contratual, documentos relativos ao acompanhamento da execução do ajuste e pagamentos feitos à empresa contratada (fls. 2.164/2.172).

O Ministério Público manifestou-se a respeito da inexistência de conexão com os feitos nº 1032933-59.2014 e 1042344-29.2014 que correm perante o MM. Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital (fls. 2.200/2.205).

A Municipalidade de São Paulo veio aos autos para juntar os documentos determinados na decisão inicial (fls. 2.232/3.144).

Os requeridos apresentaram defesas prévias.

O Ministério Público requereu o aditamento da inicial para adequar o valor atribuído à causa (fls. 3.579/3.581).

O aditamento à inicial foi recebido pela decisão de fls. 3.668/3.669.

Por fim, o Ministério Público apresentou réplica, reiterando os termos da inicial.

A decisão de fls. 3.688/3.705 afastou a conexão em relação às ações 1032933-59.2014.8.26.0053 e 1042344-29.2014.8.26.0053, bem como rejeitou a ação apenas em relação ao requerido Bruno Covas Lopes e, no mais, recebeu a petição inicial em face dos demais requeridos. Seguiu-se embargos de declaração (fls. 3.742/3.744), que foram rejeitados.

O RMP noticiou a interposição de agravo de instrumento (fls. 3.761/3.762). De igual modo, foram interpostos recursos de agravo de instrumento pelos requeridos Marcos Rodrigues Penido (fl. 3.826) e Vitor Levy Castex Aly (fl. 3.846).

MARCOS RODRIGUES PENIDO ofereceu CONTESTAÇÃO (fls. 3.882/3.908).

MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO reiterou manifestação anterior (fls. 3.922/3.941).

RAPHAEL DO AMARAL CAMPOS JUNIOR apresentou CONTESTAÇÃO. No mérito, refutou ter o DER obrigação de realizar a manutenção do viaduto indicado, conforme parecer da Procuradoria Geral do Estado exarado no processo administrativo nº 004037/07/0000/00/2018, em que se concluiu que as áreas das Marginais se transformaram em viário municipal, tornando-se, em consequência, bem público municipal em razão de afetação, independente do registro imobiliário. Disse que não partiu de sua lavra qualquer ato para contratar a empresa para obra emergencial, porque não possui qualquer vínculo com o Município e não detém meios, recursos e atribuição para contratar obras de intervenção no viário municipal, o que leva à inexistência de ato de improbidade. Argumentou a inexistência de dolo ou má-fé. Requereu a improcedência do pedido (fls. 3.957/3.976).

JZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA também CONTESTOU (fls. 3.977/4.015).

VITOR LEVY CASTEX ALY ofereceu CONTESTAÇÃO (fls. 4.188/4.230).

O RMP manifestou-se em RÉPLICA (fls. 4.247/4.258).

Sobreveio decisão proferida pelo E. TJSP no julgamento dos agravos de instrumentos interpostos em face da decisão de recebimento da ação, concedendo-se efeito suspensivo (fls. 4.262/4.265).

Determinou-se a suspensão do feito até o julgamento dos recursos (fl. 4.270).

O Agravo de Instrumento nº 2230615-91.2019.8.26.0000 interposto pelo requerido Marcos Rodrigues Penido em face da decisão de recebimento da inicial, restou provido já transitado em julgado (fls. 4.313/4.343).

O RMP noticiou o falecimento do requerido Bruno Covas Lopes (fl. 4.412), bem como que o E. TJSP negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a ação de improbidade em face dele (fls. 4.422/4.452).

Sobreveio notícia do julgamento dos Embargos de Declaração nº 2236962-43.2019.8.26.0000/50000, que foi acolhido com efeitos infringentes para rejeitar a ação em face dos requeridos Vitor Levy Castex Aly e JZ Engenharia.

O Juízo determinou o prosseguimento do feito apenas em relação ao corréu Raphael do Amaral Campos Júnior. Diante da recente alteração da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), produzida pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, determinou a manifestação do RMP para que, se o caso, aditasse a petição inicial, indicando o cabimento da demanda (fls. 4.502/4.503).

O RMP manifestou-se às fls. 4.630/4.635.

O requerido RAPHAEL DO AMARAL CAMPOS JÚNIOR manifestou-se em seguida (fls. 4.644/4.653).

Relatados. FUNDAMENTO e DECIDO.

É caso de julgamento antecipado e integral da lide, conforme artigos 354/5 e 370, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, dispensando-se dilação probatória na medida em que incontroversos os fatos. A divergência gira exclusivamente em torno da aplicação do direito, e a partir dele, extrair consequências. Assim, examino desde logo como medida de celeridade constitucional e legal. Ainda, para fins do artigo 12 do Código de Processo Civil registro que tenho

julgado os processos conclusos em curto espaço de tempo, sem caracterização de atraso, observando preferencialmente a ordem cronológica (Lei Federal 13.105/15 alterada pela Lei Federal 13.256/16).

Ausentes preliminares ou prejudiciais pendentes, passo ao finalmente ao mérito.

A demanda trazida a conhecimento se insere no âmbito da responsabilidade por prática de ato de improbidade administrativa.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCEITO E ALCANCE.

No plano NORMATIVO, situo o tema. Em linha geral, a improbidade administrativa costumeiramente é definida apenas como forma de moralidade qualificada a que se submete e que se exige dos agentes públicos e dos particulares colaboradores. A rigor, é conceito mais denso. Trata-se da conduta divergente das normas morais, da lei e/ou dos costumes, indicando desonestidade dolosa em relação aos procedimentos esperados da administração pública, aqui em sentido amplo. Com mais propriedade, Marino Pazzagli Filho define que "Numa primeira aproximação, improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, democrático e Republicano), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo "tráfico de influência" nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos".

Mais a frente pontua:

De forma geral, a improbidade administrativa não reclama tanta elaboração para que seja reconhecida. Estará caracterizada sempre que a conduta administrativa contrastar qualquer dos princípios fixados no art. 37, caput da CF (legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade), independentemente da geração de efetivo prejuízo ao erário.

Apesar da Lei Federal que trata do tema datar de 1992 [Lei Federal 8.429/1992], o conceito último não é vago. Diz muito, sobretudo nos tempos atuais em que Brasil parece finalmente repudiar veementemente a vexatória situação de degradação moral em que os agentes públicos e particulares não raramente são surpreendidos. Da abstração dos princípios às técnicas exemplificativas dos artigos 9 a 11 da Lei Federal 8.429/1992, tenho por improbidade administrativa como sendo a quebra qualificada dos princípios norteadores do agente honesto.

DAS ALTERAÇÕES RECENTES PROMOVIDAS PELA LEI Nº. 14.230/21 E O JULGAMENTO DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL.

Como é de conhecimento geral, a Lei nº. 14.230/21, publicada em 25 de outubro de 2021, promoveu relevantes alterações na Lei nº. 8.429/92 que trata da prática de atos de improbidade administrativa, sanções e procedimento judicial. Dentre as alterações perpetradas, merece destaque especial para o caso em tela a supressão do ato de improbidade administrativa praticado mediante culpa, bem como a especificação realizada pelo artigo 1º, § 2º, da LIA que exige dolo específico do agente para configuração do ato ímprobo, isto é, "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos

arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

A questão foi submetida a julgamento pelo C. STF nos autos do ARE 843989, afetado ao Tema 1199 da Repercussão Geral. Recentemente, em 18 de agosto de 2022, o julgamento foi concluído e fixadas as seguintes teses:

- 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;
- 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
- 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposos, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.
- 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Deste modo, ao caso em tela, aplicam-se as novas regras estabelecidas pela Lei nº. 14.230/21, com exceção do novo regime prescricional.

Feitas as considerações essenciais, passo à demanda concreta.

FATOS. CAUSA DE PEDIR E CONDUTA.
ACUSAÇÃO E PROVAS.
CONCLUSÃO.

No plano FÁTICO, a causa de pedir decorre da apuração em inquérito civil de omissão na manutenção e fiscalização do estado dos viadutos do Município de São Paulo, que teria ocasionado o acidente ocorrido no dia 15 de novembro de 2018 no Viaduto T-5 localizado na Marginal Pinheiros/Leste Via Expressa. Em razão do referido acidente, a Municipalidade de São Paulo efetuou a contratação da empresa JZ Engenharia e Comércio Ltda com dispensa de licitação em virtude da urgência, para realizar as obras de recuperação do viaduto.

É certo que a ação atualmente tramita apenas em face do requerido RAPHAEL DO AMARAL CAMPOS JÚNIOR que era Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo à época. Os demais requeridos tiveram seus recursos providos pelo E. TJSP com a rejeição da ação em face deles.

O autor defende a prática de ato de improbidade administrativa pelo requerido Raphael, consubstanciado nos artigos 10, inciso VIII (“frustra a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial”) e 11, caput (“que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade”), ambos da LIA. Argumentou que os documentos comprovaram que o desabamento do viaduto ocorreu por ausência de manutenção e que tal fato era de conhecimento do requerido, bem como o risco de desabamento da obra de arte. Por tal motivo, a contratação emergencial da empresa JZ para recuperação do viaduto decorreria de uma emergência “fabricada” pelo agente público, não encontrando amparo legal.

Pois bem.

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que em 2012 foi iniciado o processo de transferência da propriedade da obra do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ao Município de São Paulo. Inclusive, como relatou a Municipalidade de São Paulo nos autos, no mesmo ano efetivou a contratação de serviços técnicos para o levantamento e diagnósticos preliminares das condições das OAEs localizadas no Município, inclusive do viaduto em tela, definindo critérios de priorização para o planejamento das obras e serviços de recuperação ou reforço estrutural.

Como bem apontou o requerido em sua contestação, veja-se o Protocolo de Intenções celebrado entre o Estado de São Paulo e o Município de São Paulo após o acidente (fls. 3.659/3.664). A cláusula segunda "Da Implementação" assim prescreve:

2.1 Para o atingimento do escopo apontado na Cláusula Primeira deste Protocolo de Intenções, os signatários comprometem-se a desenvolver atividades conjuntas voltadas aos seguintes objetivos:

- a) analisar e, no que couber, regularizar a situação dominial dos imóveis componentes das Marginais dos Rios Pinheiros e Tietê, construídos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP), adotando os atos necessários para o eventual reconhecimento da propriedade do Município de São Paulo, em razão da afetação ao viário municipal;
- b) outorgar ao Estado de São Paulo, mediante o instrumento jurídico que se revelar adequado:
 - (b.1) a disponibilidade do uso da infraestrutura física correspondente às Marginais dos Rios Pinheiros e Tietê, incluindo os trechos construídos pelo DER/SP e pelo Município de São Paulo;

De igual modo deve-se considerar que, após o acidente, a própria Municipalidade de São Paulo realizou a contratação da empresa JZ para recuperação do viaduto, cujo contrato, formalizado com dispensa de licitação, também é alvo da presente ação de improbidade administrativa.

Por certo que, na condição de Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, ao requerido não é possível imputar prática de qualquer ato ímprobo. Seja pela omissão na fiscalização, uma vez que a obra de arte já era de responsabilidade do Município de São Paulo, seja em relação à contratação supostamente ilegal realizada também pela Municipalidade.

O DER/SP é autarquia estadual vinculada ao Estado de São Paulo, não possuindo, portanto, qualquer ingerência sobre o referido contrato administrativo firmado pelo órgão municipal.

Não se descuida, inclusive, como já ressaltado, que a legislação de regência exige a demonstração de dolo específico do agente ímprobo, isto é, vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, o que, no caso dos autos, não restou demonstrado.

O requerido foi nomeado para o referido cargo em maio/2018 (fl. 3.654), meses antes do acidente ocorrido em novembro/2018, razão pela qual é impossível imputar a ele a alegada omissão na manutenção do viaduto, cuja situação precária já era de conhecimento dos demais gestores há muitos anos.

Como bem pontuou a Exma. Des. Relatora SILVIA MEIRELLES, nos Embargos de Declaração Cível nº 2259466-43.2019.8.26.0000/50000, no Agravo de Instrumento interposto pelos demais requeridos nestes autos e que se aplica também à situação do requerido:

"(...) Sob este prisma, não há como responsabilizá-lo, na seara da ação de improbidade administrativa, pelo problema estrutural que já ocorria, em virtude da negligência de administrações anteriores, e que foi o fator determinante que gerou a queda do referido viaduto.

Além disso, como visto supra, é necessário um plus ao ato irregular para que este seja configurado como ímprobo, uma vez que esta ação não serve para punir os agentes inaptos, mas, sim, ímprobos e corruptos. Desse modo, seria desproporcional e desarrazoado imputar-se a conduta omissiva geradora do evento danoso ao embargante, que exerceu o cargo por breve período de tempo. (...)”

Portanto, inexistente conduta ímproba a ser imputada ao requerido Raphael.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas ex lege.

Considerando que se trata de ação de assento constitucional que tutela direitos difusos superiores da comunidade e/ou cidadania, ressalvados os casos de comprovada má-fé, por força legal (art. 23-B, § 2º, da LIA), não se impõe a condenação de custas, despesas e honorários de advogado. Logo, deixo de fixar qualquer sucumbência.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de agosto de 2022.

RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA

Juiz de Direito

Documento Assinado Digitalmente